

1003011-33.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... seu aparelho celular roubado.

A ré não nega que o roubo aconteceu e que as operações foram realizadas por terceiro (fl. 58). Logo, é fato incontroverso.

É fato notório (art. 374, I, do CPC) que a instituição financeira dispõe de recursos tecnológicos para obstar operações bancárias quando se desviam do normal perfil de uso do consumidor (TJSP; Apelação Cível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

2ª Vara Cível

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo - SP - cep 08240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003011-33.2022.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003011-33.2022.8.26.0007

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Gabriela Santos Braz Aversan

Requerido:

Banco Original S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda

Vistos.

Trata-se de processo em trâmite pelo rito comum proposto por Gabriela Santos Braz Aversan contra Banco Original S.A.

Na inicial (emendada às fls. 191/193), a parte autora alega que: a) seu celular foi roubado; b) foram realizadas múltiplas operações bancárias indevidas em seu nome.

Pede: a) declaração de inexigibilidade de débito; b) indenização por danos morais; c) indenização por danos materiais.

Concedida a gratuidade da justiça (fl(s). 52/52).

Regularmente citada (fl(s). 56), a parte ré contestou (fls. 57/87). Alega: a) ilegitimidade passiva; b) não cabimento de justiça gratuita; c) inexistência de obrigação de indenizar; d) validade dos empréstimos; e) inexistência de dano moral.

Réplica à(s) fl(s). 157/178.

É o relatório.

Decido.

A inicial foi emendada, e não aditada. Logo, não se aplica ao caso o art. 329 do CPC.

Rejeito a impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte demandante, porque não provado que tem condições de arcar com as despesas do processo.

Pela Teoria da Asserção, o juiz deve examinar a presença das condições da ação com base no quanto afirmado pelo autor na petição inicial. Assim, sua decisão acerca daquelas deve ser “fruto de uma cognição sumária, sem que tenha havido qualquer espécie de instrução” (DA COSTA, Susana Henriques. Condições da ação, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 43). Tal posição é adotada pelo STJ (Resp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011; AgRg no Resp 1095276/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 11/06/2010).

De acordo com a narrativa da inicial, a parte ré é titular da obrigação correspondente ao direito subjetivo material reclamado. Por isso, reconheço sua legitimidade passiva.

A relação travada entre as partes se rege pelo CDC, pois há prestação de serviço a destinatário final (art. 2º do CDC).

Os documentos acostados ao processo fazem verossímeis as alegações da parte autora. Por essa razão, inverte o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Não é o caso de designar audiência de conciliação, pois as partes não manifestaram interesse em composição.

Segundo entendimento do STJ, “não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido tal pedido, na inicial” (STJ, AgRg no Resp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013).

O disposto no art. 370 do CPC/2015 (correspondente ao art. 130 do CPC/1973) estabelece que, em ações envolvendo direito disponível, é faculdade do julgador, e não um dever, determinar de ofício a produção de provas, não lhe cabendo suprir o ônus das partes (RESP 471.857/ES, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2003, DJ 17/11/2003, p. 207).

No mesmo sentido, já decidiu o TJSP (TJSP; Apelação 1073920-59.2015.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2018; Data de Registro: 17/01/2018 e TJSP; Apelação 1042253-58.2015.8.26.0002; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro: 08/03/2017).

Não foi requerida a produção de outras provas.

Sendo assim, cabe julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.

A parte autora impugna operações realizadas com aplicativo de internet instalado em seu aparelho celular roubado.

A ré não nega que o roubo aconteceu e que as operações foram realizadas por terceiro (fl. 58). Logo, é fato incontroverso.

É fato notório (art. 374, I, do CPC) que a instituição financeira dispõe de recursos tecnológicos para obstar operações bancárias quando se desviam do normal perfil de uso do consumidor (TJSP; Apelação Cível 1007398-44.2018.8.26.0068; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021; TJSP; Apelação Cível 1001936-72.2016.8.26.0102; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cachoeira Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021).

Tal bloqueio não foi tempestivamente realizado e não há prova de que as operações impugnadas se amoldavam ao perfil da parte autora.

O art. 422 do CC, lei federal, estabelece cláusula geral de boa-fé objetiva aplicável aos contratos em geral. Dela decorre o dever de proteção, assim definido por Costa (COSTA, Judith Martins. A boa-fé no direito privado: Critérios para sua aplicação. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 598-599):

Assim como os deveres anexos ao dever de prestar, os de proteção têm como fonte jurídica a boa-fé. [...] A sua correlação é com os interesses de proteção. Correspondem aos interesses de proteção: a) os deveres de proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte, [...]; b) os deveres de omissão e de segredo,

[...]; c) os deveres referentes ao resguardo da esfera jurídica de terceiros eventualmente atingidos pelo contrato. Excepcionalmente, se apresentam, sob a forma de ônus jurídico, em relação à proteção da própria esfera de interesses do credor, implicando, porém, colaboração com interesses de terceiros.

Num contexto brasileiro de recorrentes e sabidas fraudes perpetradas com cartões e aplicativos bancários, várias das quais com uso de senha pessoal do consumidor, e de forte corrente jurisprudencial que reconhece a responsabilidade da instituição bancária em tais situações, gerando expectativa no consumidor-contratante de que o banco atue de forma ativa para evitar tais fraudes, a exigência de bloqueio das operações e de contato com o cliente para sua confirmação destoam de seu perfil de consumo, é o mínimo que se pode esperar do fornecedor para evitar dano ao consumidor.

Se à praticidade da tecnologia se contrapõe um maior risco de fraude, cabe ao fornecedor redobrar as cautelas para evitar tal fraude, pois não é razoável o risco (art. 14, § 1º, II, do CDC) de que qualquer pessoa faça uso de aplicativo de internet bancário à revelia de seu titular.

Assim, deve prevalecer a alegação da parte autora no sentido de que terceiro não autorizado realizou:

a) as transferências via Pix de R\$ 1.999,98, R\$ 1.960,00 e R\$ 1.000,00 (fls. 28/29);

b) as transferências via Pic Pay de R\$ 1.000,00, R\$ 1.100,00 e R\$ 100,00 (fls. 39/41);

c) o empréstimo de R\$ 5.168,79 (fl. 28).

As prestações do empréstimo não devem ser cobradas da autora.

Terceiro teve acesso aos depósitos e aos recursos bancários da parte autora, indicando falha de segurança do serviço bancário. Com isso, a parte ré, na qualidade de fornecedora (art. 3º, caput, e § 2º do CDC), realizou prestação defeituosa (art. 14, § 1º, do CDC), que teve por vítima a parte demandante (art. 2º e art. 17 do CDC). Desse ato decorre responsabilidade objetiva, na forma do art. 14 do CDC.

Ainda que presente fraude praticada por terceiro, há responsabilidade da parte ré, nos termos da Súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O patrimônio da parte autora foi desfalcado em R\$ 7.159,98 em virtude das transferências indevidas. Este deve ser o valor da indenização por danos materiais. O art. 1º da Lei n 6.899/1981 estabelece que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Será contada de quando liquidado o dano, ou seja, de cada transferência indevida.

A responsabilidade decorre de ilícito praticado no curso da execução de contrato. Portanto, os juros de mora são contados da citação, nos termos do art. 405 do CC (AgInt no AREsp 869.645/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016). Incidirão de forma simples, à razão de 1% ao mês (arts. 397 e 406 do CC e do art. 161, § 1º, do CTN).

Julgado do STJ define dano moral como a "lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e social da personalidade." (REsp n. 1.673.064/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 25/8/2017).

É natural e esperado que intercorrências ocorram no curso do cumprimento de um contrato, demandando empenho adicional das partes para sua solução. Assim, não é qualquer fato do tipo que se pode reputar lesivo e ensejar de obrigação de indenizar. Esta depende da violação real de um direito da personalidade por força do dispêndio significativo de tempo empregado para a resolução de um problema que,

em condições normais, poderia ser solucionado em tempo menor.

Deste modo, para a caracterização do dano moral por desvio produtivo, necessária a prova de que a situação vivenciada pela parte demandante prejudicou concretamente o desempenho de outras tarefas (TJSP; Apelação Cível 1031481-26.2021.8.26.0002; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022).

Tal prova não foi produzida pela parte demandante, razão pela qual não há dano moral a indenizar.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

a) declarar inexigíveis as prestações do empréstimo de R\$ 5.168,79, devendo o réu se abster de realizar qualquer cobrança a esse título e a excluir de cadastro de proteção ao crédito eventual apontamento, sob pena de multa de R\$ 200,00 por cada ato de cobrança;

b) condenar a parte ré a pagar à parte autora indenização por danos materiais no valor de R\$ 7.159,98, corrigida pela Tabela Prática do TJSP desde janeiro de 2022 e acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação.

A indenização acima deve ser compensada com o depósito de R\$ 5.168,79 realizado em favor da autora em razão do empréstimo.

Certo o direito alegado e presente o risco de dano irreparável, concedo a tutela de urgência referente ao provimento declaratório de inexigibilidade de débito. Intime-se a parte ré por carta.

Dada a sucumbência recíproca:

a) cada parte arcará com metade das despesas processuais;

b) a parte autora pagará aos patronos da parte ré honorários advocatícios de 10% de R\$ 15.000,00 (proveito econômico aproximado dos pedidos julgados improcedentes), com correção da distribuição do processo e juros de mora da 1% ao mês do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC);

c) a parte ré pagará aos patronos da parte autora honorários advocatícios de 10% de R\$ 12.500,00 (proveito econômico aproximado dos pedidos julgados procedentes), com correção da distribuição do processo e juros de mora da 1% ao mês do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC).

Observe-se a gratuidade da justiça.

Passados 30 dias do trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos, independentemente de nova intimação das partes. Eventual pedido de cumprimento de sentença forçado (art. 523 do CPC) ou voluntário (art. 526 do CPC) deve ser deduzido por incidente, na forma dos arts. 917, caput, I, e 1.285 das Normas de Serviço da CGJ/TJSP, do Comunicado CG nº 1789/2017 e da Resolução CNJ nº 65/2009. A questão é expressamente tratada na cartilha "Cautelas para evitar erros frequentes: Novo MovJud" elaborada pelo E. TJSP (), da qual consta o seguinte: "Nos termos do Comunicado CG nº 1789/2017, requerido o cumprimento de sentença por peticionamento intermediário, no ato do cadastramento do pedido o sistema adotará a tramitação em apartado, com geração de numeração própria. Os futuros peticionamentos intermediários deverão ocorrer no cumprimento de sentença incidental. [...] O cumprimento de sentença não deve, em hipótese alguma, ser entranhado nos autos do processo de conhecimento, pois nesse caso não será possível registrar a informação de que o processo principal já está encerrado". Sendo assim, desde já indefiro a realização de depósito ou o levantamento, nestes autos (o levantamento poderá ser requerido em incidente), de depósito aqui já realizado a título de pagamento de condenação.

O desarquivamento dos autos dependerá de prévio recolhimento de taxa (Comunicado TJSP nº 211/2019), a menos que a parte requerente seja beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.